

- **Expediente N.º: EXP202305306**

- RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: **A.A.A.** (en adelante, la parte reclamante) con fecha 1 de marzo de 2023 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra **ILUROBOX, S.L.** con NIF **B67030270** (en adelante, la parte reclamada).

En dicho escrito la parte reclamante expone que ha sido incluido, junto a otras 150 personas más, en un grupo de WhatsApp a través del cual la parte reclamada enviaba comunicaciones. Manifiesta que, si bien mantuvo un contacto previo con ésta, en ningún caso dio su consentimiento para recibir tales comunicaciones ni para formar parte de ningún grupo de mensajería instantánea.

En la reclamación aportado se indican también los datos de la parte reclamada, entre los cuales se encuentra la dirección de la página web de la misma: <https://www.boxmotorsport.com>. Dentro de dicha página web, como teléfono de contacto, figura el número de teléfono a través del cual se creó el grupo de mensajería instantánea.

Junto al escrito de reclamación se aporta la siguiente documentación:

- Una captura de pantalla donde se visualiza la opción de inscripción en el servicio de Listas Robinson de la línea telefónica *****TELÉFONO.1**, de la cual es titular de la parte reclamante. De dicha captura, sin embargo, no se deduce claramente si se ha procedido a la inscripción efectiva en dicho servicio.
- Una captura de pantalla donde se visualiza el chat de un grupo con el nombre de *****GRUPO.1** creado por un usuario denominado *****USUARIO.1**. En los comentarios de dicho chat se aprecia la sorpresa de varios participantes del grupo que se cuestionan sobre el motivo de la creación de dicho grupo de mensajería.
- Una captura de pantalla del contacto *****USUARIO.1** donde se muestra el número de teléfono *****TELÉFONO.2** el cual corresponde a dicho contacto.
- Una captura de pantalla donde figura una conversación por mensajería instantánea entre la parte reclamante y el contacto *****USUARIO.1** relacionada con la compraventa de unas llantas de un vehículo.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos.

El traslado, que se practicó mediante notificación electrónica conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), no fue recogido por el responsable, dentro del plazo de puesta a disposición, entendiéndose rechazada conforme a lo previsto en el art. 43.2 de la LPACAP en fecha 07/05/2023, como consta en el certificado que obra en el expediente.

Aunque la notificación se practicó válidamente por medios electrónicos, dándose por efectuado el trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 41.5 de la LPACAP, a título informativo se envió una copia por correo postal. En dicha notificación, se le recordaba su obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración, y se le informaba de los medios de acceso a dichas notificaciones, reiterando que, en lo sucesivo, se le notificaría exclusivamente por medios electrónicos.

El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), no fue recogido por el responsable; reiterándose el traslado en fecha 24/05/2023 por correo postal certificado, el cual fue nuevamente devuelto por “ausente”.

No se ha recibido respuesta a este escrito de traslado.

TERCERO: Con fecha 1 de junio de 2023, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

CUARTO: Con fecha 2 de noviembre de 2023, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, por la presunta infracción del Artículo 6.1 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.

QUINTO: Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) y transcurrido el plazo otorgado para la formulación de alegaciones, se ha constatado que no se ha recibido alegación alguna por la parte reclamada.

El artículo 64.2.f) de la LPACAP -disposición de la que se informó a la parte reclamada en el acuerdo de apertura del procedimiento- establece que si no se efectúan alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, cuando éste contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, podrá ser considerado propuesta de resolución. En el presente caso, el acuerdo de inicio del expediente sancionador determinaba los hechos en los que se concretaba la imputación, la infracción del RGPD atribuida a la reclamada y la sanción que podría

imponerse. Por ello, tomando en consideración que la parte reclamada no ha formulado alegaciones al acuerdo de inicio del expediente y en atención a lo establecido en el artículo 64.2.f) de la LPACAP, el citado acuerdo de inicio es considerado en el presente caso propuesta de resolución.

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La parte reclamante ha sido incluida en un grupo de WhatsApp junto a otras personas, a través del cual la parte reclamada enviaba comunicaciones. Este hecho se desprende de la captura de pantalla del chat del grupo de WhatsApp denominado "****GRUPO.1" creado por un usuario denominado "******USUARIO.1**".

SEGUNDO.- Queda acreditado que "******USUARIO.1**" es un contacto de la parte reclamante al que le corresponde el número de teléfono *****TELÉFONO.2**. Este hecho se manifiesta en la captura de pantalla del contacto que la parte reclamante aportó junto a su escrito.

TERCERO.- La incorporación al grupo de mensajería instantánea se produjo sin un previo consentimiento de la parte reclamante y de otros participantes en dicho grupo. Este hecho se deduce de la propia manifestación de la parte reclamante que afirma no haber consentido ningún tipo de comunicación de carácter comercial. Asimismo, viene reafirmado de las propias capturas aportadas por la parte reclamante donde se aprecia la sorpresa de varios participantes, los cuales cuestionan el motivo de la creación del grupo.

CUARTO.- En la política de privacidad de la dirección de página web de la parte reclamada que fue indicado en el escrito de reclamación, figura diversa información de la misma entre la cual se encuentra el número de teléfono de contacto. Dicho número de contacto coincide con el mismo que creó el grupo de mensajería instantánea.:

"¿Quiénes somos?

Nuestra denominación: ILUROBOX SL

Nuestro CIF / NIF: B67030270

Nuestra actividad principal: Taller mecánico de reparación de vehículos y motocicletas

Nuestra dirección: C/ Remences 26 local 1, CP 08304, Mataró (Barcelona)

*Nuestro teléfono de contacto: *****TELÉFONO.2***

Nuestra dirección de correo electrónico de contacto: : info@boxmotorsport.es

Nuestra página web: boxmotorsport.com

Para su confianza y seguridad, le informamos que somos una entidad inscrita en el siguiente Registro Mercantil /Registro Público:

Estamos a su disposición, no dude en contactar con nosotros."

QUINTO.- Se confirma la existencia de una conversación previa, a través de mensajería instantánea, entre la parte reclamante y el contacto "******USUARIO.1**" relacionada con la compraventa de unas llantas de un vehículo. Ello se desprende de

la captura de pantalla de parte de dicha conversación que aporta la parte reclamante junto a su escrito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia

De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *"Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."*

II

Obligación incumplida del artículo 6.1 RGPD

El artículo 6 del RGPD, relativo al principio de licitud del tratamiento dispone en su artículo primero lo siguiente:

"1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del

interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones”.

Por tanto, para que un tratamiento de datos se considere lícito, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo, requiere la existencia de una base legal que lo legitime. En el caso que nos ocupa, de la documentación aportada junto a la reclamación no se desprende la existencia de alguna causa que legitime el tratamiento de los datos personales de la parte reclamante.

El mencionado tratamiento consistió en la incorporación de la parte reclamante junto a otros participantes a un grupo de mensajería instantánea creado por la parte reclamada, lo que permitió que todos ellos pudieran visualizar datos personales del resto.

La actuación consistente en la incorporación de determinados contactos a un grupo de mensajería cumple las características exigidas para considerarlo como un tratamiento de datos personales en los términos establecidos por el artículo 4 del RGPD. Este artículo define al tratamiento como *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”*

La aplicación de mensajería instantánea utilizada fue WhatsApp, aplicación que permite la creación de grupos con diversos participantes sin el consentimiento de estos y donde los mismos pueden, además, visualizar el número de teléfono del resto, así como su alias y su foto de perfil. Todos estos datos tienen la consideración de datos personales en los términos establecidos en el artículo 4 del RGPD que los define como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”*.

Dicho tratamiento ilícito se deduce de la documentación aportada por la parte reclamante, entre la cual se encuentra una copia de parte de las conversaciones del mencionado grupo de WhatsApp. En dicha conversación no se desprende consentimiento alguno por la parte reclamante, ni tampoco de otros participantes, los cuales manifiestan su sorpresa de haber sido incluido en dicho grupo y el desconocimiento del motivo de su incorporación. La creación del grupo de mensajería, tal y como resulta de la propia copia de la conversación, fue realizada por el número teléfono *****TELÉFONO.2** que llevaba como alias **“***USUARIO.1”**. Tal y como se indica en el hecho probado tercero, dicho número de teléfono coincide con el número de contacto que se muestra en la página web de la parte reclamada.

Conviene añadir que, previamente a la creación del mencionado grupo de WhatsApp, se produjo otra conversación a través de esa misma aplicación entre la parte reclamada y la parte reclamante, tal y como figura en una copia de conversación de WhatsApp aportada asimismo junto a la reclamación. Sin embargo, del contenido de la conversación no se desprende consentimiento ni voluntad alguna por la parte reclamante de pertenecer a ningún grupo de WhatsApp de cualquier naturaleza. De la misma forma, los comentarios de sorpresa que se muestran en la conversación del grupo creado parecen manifestar que la falta de consentimiento no se limita únicamente a la parte reclamante, sino también a otros participantes.

En base a lo expuesto, se deduce que la incorporación de la parte reclamada a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento y sin que concurra ninguna otra causa que la legitime supone un tratamiento ilícito de los datos personales, lo que conlleva una vulneración del mencionado artículo 6.1 del RGPD.

III

Tipificación y calificación de la infracción por incumplimiento del artículo 6.1 del RGPD

La vulneración del artículo 6.1 del RGPD por la parte reclamada supone la concurrencia de la infracción tipificada en el artículo 83.5 a) del RGPD, que establece que se sancionarán, con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:

“a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;”

Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 71, Infracciones, señala que: *“Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica”.*

Por lo que se refiere al plazo de prescripción, según el artículo 72 de la LOPDGDD *“se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:*

[...]

b) El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. (...)

IV

Sanción por incumplimiento del artículo 6.1. del RGPD

A fin de establecer la multa administrativa que procede imponer han de observarse las previsiones contenidas en los artículos 83.1 y 83.2 del RGPD, que señalan:

“1. Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas administrativas con arreglo al presente artículo por las infracciones del presente

Reglamento indicadas en los apartados 4, 5 y 6 sean en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y j).

Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta:

a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;

b) la intencionalidad o negligencia en la infracción;

c) cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;

d) el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;

e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;

f) el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;

g) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;

h) la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;

i) cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;

j) la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42,

k) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.”

En el presente supuesto se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con las siguientes circunstancias que establece el artículo 83.2 del RGPD, en los siguientes términos:

“a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;”

En el presente supuesto, se estima la concurrencia de la mencionada agravante atendiendo a su alcance, dado que, como consecuencia del tratamiento ilícito han podido tener acceso a los datos personales de la parte reclamante al menos otras personas que formaban parte del grupo de Whatsapp y entre los cuales se encontraban números de teléfono, fotos de perfil y el alias cuando no se tiene guardado el contacto, lo cual implica una mayor gravedad en la operación del tratamiento.

Teniendo en cuenta las condiciones generales establecidas por el ya mencionado artículo 83.5 del RGPD, atendiendo a las circunstancias del presente supuesto y la concurrencia de las circunstancias mencionadas, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento, se considera adecuado fijar como posible sanción una multa de cuantía de **3.000 € (TRES MIL EUROS)**.

V

Adopción de medidas

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 58.2 d) del RGPD, cada autoridad de control podrá *“ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado...”*. La imposición de esta medida es compatible con la sanción consistente en multa administrativa, según lo dispuesto en el art. 83.2 del RGPD.

En el presente supuesto, se requiere al responsable para que en el plazo de dos meses notifique a esta Agencia la adopción de la siguiente medida:

- La implementación de medidas técnicas y organizativas de seguridad que impidan la creación de grupos de mensajería sin consentimiento que permitan la revelación de los datos personales asociados de los participantes, así como la eliminación, en cualquier grupo de mensajería abierto, de aquellos participantes que no hayan prestado un consentimiento previo para formar parte del mismo.

Se advierte que no atender la posible orden de adopción de medidas impuestas por este organismo en la resolución sancionadora podrá ser considerado como una infracción administrativa conforme a lo dispuesto en el RGPD, tipificada como infracción en su artículo 83.5 y 83.6, pudiendo motivar tal conducta la apertura de un ulterior procedimiento administrativo sancionador.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER a **ILUROBOX, S.L.**, con NIF **B67030270**, por una infracción del artículo 6.1 del RGPD, tipificada en el artículo 83.5 del RGPD, una multa de **3.000 euros (TRES MIL EUROS)**

SEGUNDO: ORDENAR a **ILUROBOX, S.L.**, con NIF **B67030270**, que en virtud del artículo 58.2.d) del RGPD, en el plazo de dos meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva, acredite haber procedido al cumplimiento de las siguientes medidas:

- La implementación de medidas técnicas y organizativas de seguridad que impidan la creación de grupos de mensajería sin consentimiento que permitan la revelación de los datos personales asociados de los participantes, así como la eliminación, en cualquier grupo de mensajería abierto, de aquellos participantes que no hayan prestado un consentimiento previo para formar parte del mismo.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a **ILUROBOX, S.L.**

CUARTO: Esta resolución será ejecutiva una vez finalice el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición (un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución) sin que el interesado haya hecho uso de esta facultad. Se advierte al sancionado que deberá hacer efectiva la sanción impuesta una vez que la presente resolución sea ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en el plazo de pago voluntario establecido en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso, indicando el NIF del sancionado y el número de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento, en la cuenta restringida nº **IBAN: ES00-0000-0000-0000-0000-0000 (BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX)**, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A.. En caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la

Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

938-16012024

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos